

第4節 緊急避難

刑法
No92

H18-2

(配点: 2)

月	日
月	日

刑法第37条第1項の緊急避難の法的性格について、学生AとBは、違法性阻却事由説と責任阻却事由説のいずれか異なる見解を採り、「緊急避難に当たる行為に対して正当防衛が成立し得るか。」という問題について議論したところ、学生Aは「緊急避難は成立し得るが、正当防衛は成立し得ない。」との結論になり、学生Bは「正当防衛が成立し得る。」との結論になった。学生Aが採る見解に関する記述として正しいものは、次の1から5までのうちどれか。

1. 制限従属性説を前提として、この見解を採って検討すると、正犯と従犯の関係で、正犯が緊急避難に当たる行為をした場合、正犯の幫助をした者は不可罰となる。
2. この見解は、違法性阻却の実質的理由を優越的利益の保護に求める考え方と矛盾する。
3. この見解によれば、刑法上の緊急避難に当たる行為は、民法上も損害賠償責任を問われることはない。
4. 法益の権衡が緊急避難の要件とされていることは、この見解の根拠となり得ない。
5. この見解に対しては、学生Bが採る見解から「無関係な他人のためにする緊急避難が認められていることを説明できない。」との批判がある。

No92

緊急避難の法的性格

正答率

H18-2

正解

1

78%

【学生Aが採る見解について】

緊急避難の法的性格について責任阻却事由説を採用すると、緊急避難は「不正」であり、緊急避難に対する反撃行為には正当防衛が成立し得る。他方、違法性阻却事由説を採用すると、緊急避難は「正」となり、犯罪が成立しないので、緊急避難と反撃行為の関係は「正対正」の関係に立ち、反撃行為には緊急避難が成立し得る。よって、学生Aの採用する見解は、違法性阻却事由説となる。

【学生Aが採る見解に関する記述について】

1 正しい

制限従属性説とは、共犯の従属性について正犯の行為が構成要件に該当し、かつ、違法であることを要するとする見解である。制限従属性説を論理的に貫けば、責任は行為者に向けられた人格的非難であるから、各行為者について常に個別的に判断されるが、他方で正犯者の違法性を欠く行為に対する教唆犯、従犯は考えられないことになる。よって、学生Aの見解からすると、正犯が緊急避難にあたる行為をした場合には正犯の違法性が欠けるため、正犯の幫助をした者は不可罰になる。

2 誤っている

違法性阻却の実質的理由を優越的利益の保護に求める考え方は、緊急避難こそ違法性阻却事由の基本型だとする。すなわち、避ける方法がない状態で2つの法益が衝突し合う場合、一方が生き残るため法益権衡の範囲内で他方を否定することを認めるのが、違法性阻却の原則的な考え方となる。よって、学生Aの見解は違法性阻却の実質的理由を優越的利益の保護に求める考え方と矛盾しない。

3 誤っている

民法720条によると、正当防衛と緊急避難の区別は、危難が人の不法行為に由来するか（正当防衛）、物に由来するか（緊急避難）で区別される。危難が人の適法な行為に由来する場合はそのいずれにも該当せず、これに対応する行為は不法行為となる。よって、学生Aの見解からしても、刑法上の緊急避難にあたる行為により民法上の損害賠償責任を問われることがある。

4 誤っている

違法性阻却事由説を採る学説は、37条1項本文が「生じた害が避けようとした害の程度を超えなかったこと」を要求していることを根拠とする。緊急避難を責任非難の減少により説明するのなら、バランスをとれない避難行為でも、他に方法がない避難者にとって責任は減少するはずである。よって、法益の権衡が緊急避難の要件とされていることは、学生Aの見解の根拠となり得る。

5 誤っている

責任阻却事由説を採る学説は、違法性阻却事由説から刑法が第三者のための避難も認めることを期待可能性の減少・欠如で説明するのは困難であると批判される。よって、「無関係な他人のためにする緊急避難が認められていることを説明できない」と批判されるのは、学生Bの採用する責任阻却事由説であり、学生Aの採用する違法性阻却事由説に対する批判にはなり得ない。